

0000158-92.2022.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215836/2021 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 19529518 -

DEL.POL.SÃO MANUEL, 1057/21/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2215836 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000158-92.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000158-92.2022.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215836/2021 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 19529518 -

DEL.POL.SÃO MANUEL, 1057/21/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2215836 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 07/10) em face de RODRIGO DE OLIVEIRA e de NAILÍ GABRIELLI BUENO VALARDÃO, ambos qualificados nos autos, imputando-lhes a prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06 (LD), porque, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Antônio Ivalier, n.º 81, área rural, nesta cidade e comarca de São Manuel, os réus supostamente associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, e, nas

mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os réus guardavam 08 (oito) microtubos, contendo cocaína, com peso líquido de 7,74 gramas, 05 (cinco) embalagens contendo maconha, com peso líquido de 5,94 gramas, 52 (cinquenta e duas) porções de crack, com peso líquido de 9,3 gramas e 01 (um) frasco de plástico, fechado por tampa, contendo cocaína, com peso líquido de 290,7 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, bem como 100 (cem) saquinhos de plásticos, 05 (cinco) munições de calibre 38, 01 (uma) embalagem de lanterna de cor verde e R\$ 71,65 (setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), em espécie. A acusada Nailí Gabrielli Bueno Valardão foi presa em flagrante (auto de prisão em flagrante às fls. 11/12).

A decisão de custódia de fls. 59/63 homologou a prisão em flagrante da acusada Nailí, convertendo-a em preventiva, mas substituindo, contudo, a prisão preventiva por domiciliar; ademais, foi decretada a prisão temporária do réu Rodrigo, que, porém, não foi encontrado para cumprimento do mandado.

Em cota à denúncia, a representante do Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado Rodrigo de Oliveira (fls. 02/06).

A decisão de fl. 117 determinou o desmembramento do processo em relação ao réu Rodrigo, o que gerou os presentes autos, de acordo com a certidão expedida à fl. 01.

A ré Nailí foi julgada no processo n.º 1500883-41.2021.8.26.0581, restando absolvida das imputações.

O mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado Rodrigo foi cumprido em 04/02/2022, conforme boletim de ocorrência de fls. 140/141.

Em audiência de custódia (fls. 159/160), reconheceu-se a regularidade da captura (fls. 159/160).

Devidamente notificado (fl. 165), o acusado apresentou defesa prévia (fl. 169).

Recebida a denúncia em 16/03/2022, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 170/171).

Em alegações finais escritas (fls. 235-244), a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso nos crimes do art. 33, "caput", e 35 do Código Penal, a elevação da pena-base em razão da quantidade e qualidade da droga e da presença de maus antecedentes, bem como a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A defesa, em razões escritas (fls. 248-271), pugnou pela decretação de nulidade da busca e apreensão, eis que violados os preceitos insculpidos no art. 245, § 4º, do CPP, e, no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

A teor do art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Da interpretação do referido dispositivo constitucional decorre que o ingresso no domicílio do réu seria admitido nas seguintes situações:

I) Se houvesse autorização judicial para tanto; ou

II) Se houvesse consentimento válido e inequívoco do morador; ou

III) Se houvesse fundadas razões concretas da ocorrência de flagrante delito no local.

No caso dos autos, os policiais civis alegaram conhecer o réu dos meios policiais, sabendo que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual foi requerida ordem de busca e apreensão a ser cumprida na residência do réu.

Na posse de mandado de busca e apreensão expedido por esta Vara, os agentes se dirigiram até a residência do acusado e, ao perceberem que a casa estava vazia, ingressaram no local e encontraram as drogas descritas na denúncia.

A defesa técnica sustentou a inobservância do disposto no art. 245, § 4º, do CPP, uma vez que os policiais deveriam ter solicitado a um vizinho que acompanhasse a

diligência, bem como deveriam ter encaminhado os familiares do acusado que estavam no local à delegacia de polícia, tudo a fim de corroborar para a legalidade do ingresso forçado na residência do acusado.

Passo a analisar a matéria.

Conforme se depreende dos autos, mais especificamente dos depoimentos prestados pelos policiais Rogério Aparecido Guiari e Cláudio Aparecido Leme, em operação policial que objetivava cumprir mandado de busca e apreensão na residência do acusado, restou verificado que não havia ninguém no imóvel, razão pela qual os agentes policiais ingressaram no local e encontraram as drogas descritas no auto de exibição e apreensão das fls. 19-20.

Em que pese o ingresso forçado estar autorizado no mandado, o art. 245, § 4º, do CPP dispõe sobre regra expressa e específica para a busca domiciliar em caso de morador não se encontrar na residência, exigindo-se, como bem sinalizado pela defesa, que um vizinho acompanhe a diligência, salvo impossibilidade devidamente justificada pela autoridade.

Eis o teor o referido dispositivo legal:

"Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente."

No caso em apreço, a autoridade policial ingressou na residência o acusado sem observar o disposto na legislação processual penal e tampouco justificou a ausência de vizinhos nas cercanias da residência objeto da busca e apreensão, não sendo crível inexistirem civis aptos a acompanhar a operação em virtude das fotos acostadas às fls. 12 e 13 dos autos nº 1500853-06.2021.8.26.0581, que evidenciam a existência de diversas casas e uma praça nas proximidades do imóvel objeto da diligência.

Além de notar que os policiais não fizeram qualquer menção à inexistência de vizinhos próximos que pudessem acompanhar a diligência, observo que os agentes informaram que parentes do acusados estiveram na residência no momento da busca e indicaram o paradeiro do acusado e sua companheira, fato que inclusive ensejou a prisão da corré Nalí.

No entanto, tais parentes não foram identificados, tampouco foram arrolados para comparecer na delegacia de polícia e esclarecer as circunstâncias da apreensão das drogas.

Assim, em que pese munidos de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, entendo que o cumprimento da diligência ocorreu em evidente violação ao disposto no art. 245, § 4º, do CPP, seja porque não foi acompanhada por uma testemunha civil, seja porque os parentes do acusado, que de forma incontroversa estavam presentes no momento da apreensão, não foram qualificados e encaminhados para a delegacia de polícia para esclarecer as condições em que foram realizadas as buscas da residência do acusado.

Nesse sentido, o E. TJ-SP:

"Revisão - Pedidos de absolvição e redução das reprimendas - Alegação de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei - Conhecimento. 2. Tráfico - Suficiência de provas - Irrelevante a falta de testemunhas no cumprimento do mandado de busca domiciliar, medida imprescindível apenas quando ausentes os moradores (art. 245, § 4º, do CPP)- Condenação não contrária à evidência dos autos. 3. Penas - Aumento sobre as básicas não impugnado - Adequado acréscimo pela reincidência, bem caracterizada. 4. Regime inicial - Fechado obrigatório pelo patamar da pena combinado com a recidiva." (TJ-SP - RVCr: 20849389320208260000 SP

2084938-93.2020.8.26.0000, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 24/09/2020, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/09/2020)

Dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu em desacordo com as estritas regras previstas no art. 245, § 4º, do CPP, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1º, CPP).

Impositiva, portanto, a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas.

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para ABSOLVER O RÉU RODRIGO DE OLIVEIRA da imputação da conduta típica descrita no topo do artigo artigo 33, "caput" , da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Revogo a prisão cautelar decretada às fls. 59-63.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

São Manuel, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA